

1501970-66.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, tentou fugir. Além disso, qualquer do povo pode prender em flagrante, observados os artigos 301 e 303 do CPP . Na mesma linha de entendimento:

Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recursos defensivos. Alegação de denúncia inepta. Descabimento. Preliminar relacionada à nulidade das prisões, por ilegal atuação da guarda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501970-66.2022.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501970-66.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194643/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 26205163 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2194643 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS PEREIRA PULGA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu JONATAS PEREIRA PULGA, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 19 de julho de 2.022, por volta das 01h34min, na Rua Acácio Rodrigues de Moraes, nº 730, Jardim Saltense, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, 19 de julho de 2.022, por volta das 01h34min, na Rua Acácio Rodrigues de Moraes, nº 730, Jardim Saltense, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, o acusado guardava guardava e tinha em depósito para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito: a) 30 (trinta) frascos contendo líquido transparente análogo à "lança-perfume"; b) 934 (novecentas e trinta e quatro) porções de "cocaína", acondicionadas em microtubos plásticos, com peso líquido de 493,35g (quatrocentos e noventa e três

gramas e trinta e cinco centigramas); c) 276 (duzentas e setenta e seis) porções de "THC Tetrahydrocannabinol", vulgarmente conhecido como "maconha", acondicionadas em segmentos plásticos, com peso líquido de 699,56g (seiscentos e noventa e nove gramas e cinquenta e seis centigramas); e d) 561 (quinhentas e sessenta e uma) porções de "cocaína", em sua forma petrificada, conhecida popularmente como "crack", acondicionadas em microtubos plásticos, com peso líquido de 73,25g (setenta e três gramas e vinte e cinco centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 82).

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2022. Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas comuns.

Nas alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-04), auto de exibição e apreensão (fl. 06-07), auto de constatação preliminar (fl. 08-09) e laudos de exame químico toxicológico (fls. 43-46, 79-81), laudo pericial dos objetos apreendidos (fls. 65-70) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

As testemunhas comuns Diego Guiaro de Moraes e Eduardo Henrique Aparecido de Sousa, guardas municipais, afirmaram, em síntese, que efetuavam patrulhamento pela rua Acácio Rodrigues de Moraes, visualizaram o acusado em uma bicicleta, mexendo no portão de uma residência. Ao avistar a viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou deixar o local rapidamente. Efetuaram a abordagem, nada de irregular foi encontrado em sua posse. Indagado, o réu afirmou que estava ali para vigiar entorpecentes para Adrian. O acusado franqueou a entrada dos agentes na residência. No imóvel existem 3 casas, sendo que o acusado levou os guardas municipais até a casa dos fundos, existindo no local apenas uma geladeira e uma cama. Em um dos cômodos, o acusado apontou uma sacola em que continha o valor de R\$ 1.273,00 (mil duzentos e setenta e três reais), 934 porções de cocaína, 561 porção de crack, 244 porções de maconha, 30 frascos contendo líquido, ao que tudo indica, comercializado como lança perfume. Ainda foram localizados balança de precisão, rolos de papel filme, saquinhos vazios. O acusado disse que desconhecia a quantidade de entorpecentes.

Adrian Henrique Camargo de Moraes, na fase policial, declarou que soube da prisão de Jonatas Pereira Pulga na porta da residência dos fatos ocorridos. Não tem informação sobre os fatos ocorridos, muito menos informações sobre o acusado.

Declarou ser usuário de maconha, mas nunca comercializou drogas (fls. 38).

O réu, Jonatas Pereira Pulga, interrogado judicialmente, negou os fatos. Disse que apenas foi até o local para tomar conta da casa a pedido de Adrian. Não foi fumar maconha com outras pessoas no local, conforme afirmado anteriormente na fase policial.

Os guardas municipais apresentaram versão firme e coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu guardava e tinha em depósito grande quantidade de entorpecentes, sendo encontrados em uma residência aparentemente desabitada 30 (trinta) frascos contendo líquido transparente análogo à "lança-perfume"; 934 (novecentas e trinta e quatro) porções de "cocaína", com peso líquido de 493,35g (quatrocentos e noventa e três gramas e trinta e cinco centigramas); 276 (duzentas e setenta e seis) porções de "THC Tetrahydrocannabinol" com peso líquido de 699,56g (seiscentos e noventa e nove gramas e cinquenta e seis centigramas); e 561 (quinhentas e sessenta e uma) porções de "cocaína", em sua forma petrificada, conhecida popularmente como "crack", com peso líquido de 73,25g (setenta e três gramas e vinte e cinco centigramas), todas individualmente embaladas e prontas para a entrega a consumo e fornecimento a terceiros, além de uma balança de precisão, rolos de papel filme e saquinhos vazios, comumente utilizados para armazenar pequenas porções de drogas, tendo o acusado afirmado que estaria no local para vigiar os entorpecentes pertencentes ao amigo Adrian.

Não há ilegalidade na atuação dos guardas municipais, que abordaram o réu após fundada suspeita, considerando que o réu, após avistar a viatura, em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, tentou fugir. Além disso, qualquer do povo pode prender em flagrante, observados os artigos 301 e 303 do CPP . Na mesma linha de entendimento:

Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recursos defensivos. Alegação de denúncia inepta. Descabimento. Preliminar relacionada à nulidade das prisões, por ilegal atuação da guarda civil municipal ao prender em flagrante os acusados, em situação de flagrante permanente. Ausência de ilegalidade. Inteligência dos artigos 301 e 303 do Código de Processo Penal. Ilicitude da prova afastada. Precedentes desta 14ª Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça. Materialidade e autoria devidamente reconhecidas quanto ao tráfico. Figura típica. Idoneidade dos testemunhos dos guardas civis, ausente qualquer elemento concreto que os infirme. Impossibilidade de desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06. Manutenção das condenações. Negativa de incidência do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 para os apelantes fundada na reincidência. Regime fechado bem fixado pela recidiva e quantidade de pena. Parcial provimento dos apelos tão somente para redução das reprimendas impostas. (TJSP; Apelação Criminal 1500447-78.2022.8.26.0571; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/11/2022; Data de Registro: 07/11/2022)

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, não possuem, a priori, motivo algum para falsamente incriminar o réu. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

É possível considerar os elementos de prova produzidos na fase inquisitiva, conforme art. 155 do Código de Processo Penal. Em solo policial, Adrian declarou desconhecer os fatos e que nunca comercializou drogas.

As circunstâncias da prisão, especialmente a quantidade e variedade de entorpecente apreendido, acompanhado de instrumentos comumente utilizados para pesagem das drogas e quantia em dinheiro, denotam o intuito mercantil e, corroborados pelos demais depoimentos colhidos são suficientes a embasar o decreto condenatório.

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)". Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário, sem prova de que integre associação criminosa, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá.

Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é considerável: 30 (trinta) frascos contendo líquido transparente análogo à "lança-perfume"; 934 (novecentas e trinta e quatro) porções de "cocaína", com peso líquido de 493,35g (quatrocentos e noventa e três gramas e trinta e cinco centigramas); 276 (duzentas e setenta e seis) porções de "THC Tetrahydrocannabinol" com peso líquido de 699,56g (seiscentos e noventa e nove gramas e cinquenta e seis centigramas); e 561 (quinhentas e sessenta e uma)

porções de "cocaína", em sua forma petrificada, conhecida popularmente como "crack", com peso líquido de 73,25g (setenta e três gramas e vinte e cinco centigramas), o réu é primário (fls. 106) e não restou provado que ele integra organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de guardas municipais, sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau intermediário.

Salientando-se que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a habitualidade delitiva e participação em organização criminosa, o que não ocorre na hipótese em apreço, no qual a prisão foi realizada pela guarda municipal, sem qualquer diligência investigativa prévia. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 3 - podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base. (grifos no original). 3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria. 5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". O resultado do julgado foi assim proclamado: Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 6.

Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021). 8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que "A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021). 9. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de maconha). 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa. (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022.)

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 da repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento do celular marca LG, cor prata (fl. 96-99) e o valor de R\$ 1.273,00 (mil duzentos e setenta e três reais), pertencentes ao réu, a ser revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário (fls. 106), culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não podem ser valorados negativamente, mas devem ser valorada negativamente a natureza e diversidade das drogas apreendidas (lança-perfume, maconha, cocaína e crack) razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes e atenuantes.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, observada a quantidade de drogas apreendidas reduzo a pena em 1/6, obtendo a pena de 4 anos, 10

meses e 10 dias, e 485 dias-multa, no valor mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada, sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime é o fechado (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Diante da pena aplicada, incabível a substituição ou suspensão condicional da pena. Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu JONATAS PEREIRA PULGA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias, e 485 dias-multa, no valor mínimo legal, em regime fechado.

O réu deverá recorrer preso, considerando que se mantem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante da pena e regime ora fixados.

Decreto o perdimento do celular marca LG, cor prata (fl. 96-99) e o valor de R\$ 1.273,00 (mil duzentos e setenta e três reais) pertencentes ao réu, a ser revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006)

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet. Oportunamente, ao arquivo. Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA